中外法学 Peking University Law Journal
Vol. 19, No. 5(2007) pp. 534 - 551

“禁”还是“不禁”,这是个问题

关于“禁放令”的法律经济学分析

艾佳慧*

所有的道路都通向城市……

——凡尔哈伦[1]

(它)通向哪里并不重要,甚至不通向任何地方也不重要,无论怎样,它并不规定必须向前的方向……

——米歇尔·福柯[2]

一、问题的提出

1993 年 10 月 12 日,在广大市民的呼吁和充分征求群众意见的基础上,北京市人大通过了《北京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定》(以下简称“禁放令”),[3]该法令规定北京市八城区为“禁放区”,“在禁止燃放烟花爆竹地区,任何单位或者个人,不准生产、运输、携带、储存、销售烟花爆竹”,并且规定了违反该法规的相应处罚。[4] 随后几年,在北京的“示范效应”之下,全国共有 282 个城市通过立法禁止燃放烟花爆竹,但是近年来,随着民间呼吁燃放烟花爆竹以增加节日氛围的声音越来越高,迄止 2005 年,已有包括上海、杭州等城市的 106 个城市有

* 北京大学法学院博士生。冯象、苏力、凌斌以及李斯特、胡凌等诸多师友对本文初稿提出了细致的批评意见,谨表谢忱。另外,本文也受惠于张维迎、王锡锌教授的研究,虽然就“禁放令”而言,我并不太赞同他们的观点。最后,还要感谢北京市人大的王爱声先生和北京市政府的周永胜先生为我的研究提供了相关资料,和他们的交谈也让我对一些问题有了更全面的认识。感谢了这么多人,但文章中的一切错误和疏漏仍然是文责自负。

〔1〕 袁可嘉、董衡巽、郑克鲁选编:《外国现代派诗歌选》,第一册(上卷),上海文艺出版社 1980 年版。转引自苏力:“现代化视野中的中国法治”,载《道路通向城市》,法律出版社 2004 年版,页 3。

〔2〕 米歇尔·福柯:《必须保卫社会》,钱翰译,上海人民出版社 1999 年版,页 4。

〔3〕 具体的内容和民意数据详见,http://jpkc.ecnu.edu.cn/ggzcgl/shoukejiaoan/jueceanli/d5.doc,2006 年元月 19 日最后一次访问。

〔4〕 法规的具体内容详见《北京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定》第 4、第 5、第 6 和第 7 条。资料来源:http://news.sina.com.cn/c/2004-02-02/15452745955.shtml,2006 年元月 19 日最后一次访问。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

限解禁;具体到北京市,由于近年来该法令的执法成本很高,同时考虑到回应民意和"立法民主",北京市人大在没有预先立法安排的情况下于2005年9月9日审议和通过了《北京市烟花爆竹安全管理规定》,该法令由之前的八城区"全面禁放"改为"限定时间,限定地点"燃放(因此被很多媒体称为"禁改限"的规定,以下简称为"限放令"),同时废止实施了12年的《北京市关于禁止燃放烟花爆竹的规定》。[5]

这是一个对北京市"禁放令"甚至各地"禁放令"之"兴衰"变化的简单概括。在很多人看来,这一"解禁"体现了民意,是政府"立法民主"以及"执政为民"的具体体现之一,值得为之欢欣鼓舞;[6]在这一问题上,就连一些有洞察力的学者也在文章中明确地表示"原来加入'禁放'联盟的106个城市,已经宣布调整甚至放弃原来的立场。这可以认为是中国执法理念和执法策略上的重大进步,宣示出相当的智慧和勇气。"[7]北京的"解禁"当然也不例外。

但是,事情恐怕没有这么简单。虽然不管是当年的"禁"还是今天的"限",政府的立法几乎完全依赖于流变的"民意"(或者是表达出来的那些民意),但法律却不能仅仅根据"简单多数"来制定,"民主"在很多时候也解决不了一切问题。但退一步讲,如果不能完全依靠"民意",我们是否能够根据执法成本和现实中存在的"执法困境"而向现实妥协,甚至"改弦易张"呢?我当然承认这一考量的现实合理性和经济理性,但是仅仅根据"执法困境"的存在就改变实施了多年的法律,这个理由恐怕还不那么让人信服,而且如果只就"禁放令"而言,这一看似合理的解释在我看来却没有触及到该现象真正的核心问题。[8]

其实,就"禁放令"而言,在法学界,除了王锡锌"以禁放令的行政执法"为例的分析,相关有深度的理论分析和解释都相当缺乏。而在我的阅读范围内,经济学界的张维迎先生第一次运用博弈论的思想从法律与社会规范的理论角度讨论了"禁放令"的问题。[9] 在《法律与社会规范》一文中,张维迎指出"法学界、经济学界及其其他社会科学过去10多年的研究表明,法律的作用被人们大大高估了:社会规范(social norm),而非法律规则,才是社会秩序的主要支撑性力量(mainstay of social control)。"[10]因此,由于"法律的有效性——即法律能不能得到

---

〔5〕 从该法规的名称就可以看出该法不仅仅考虑"禁"还是"限"的问题,更多的关注点其实是放在了烟花爆竹的生产、运输和销售环节的安全管理上,但由于民众关注的主要是燃放的"有限解禁"问题,因此为了与"禁放令"对比,将之简化为"限放令"是有一定道理的。"限放"的具体规定体现在该法第12条第1款上:"本市五环路以内的地区为限制燃放烟花爆竹地区,农历除夕至正月初一,正月初二至十五每日的七时至二十四时,可以燃放烟花爆竹,其他时间不得燃放烟花爆竹。"相关规定详见《北京市烟花爆竹安全管理规定》第11条和第12条。资料来源:http://www.bj.xinhuanet.com/bjpd_bjzq/2005-10/01/content_5270124.htm,2006年元月20日最后一次访问。

〔6〕 网上一篇名为"烟花爆竹由'禁'改'限'看立法理念进步"的文章写到:"除了大量的调研、意见征集外,北京市还举行了立法听证会,在立法中充分兼顾到不同观点和不同利益群体的呼声,"因此,由人大常委会通过的《北京市烟花爆竹安全管理规定》是在"开门立法"的路上前进了一大步。资料来源:http://www.jxcoop.gov.cn/2005=11/2005118142410.htm,2006年元月20日最后一次访问;网上另外一篇文章也表明了立法应该顺应民意的看法,认为"顺应民意永远是现代政治文明最基本的原则,因此对民意完全可以给予更直接、更主动,也更制度化的回应。"参见张天蔚:"'禁放':执法成本与民意基础的困局",http://news.xinhuanet.com/comments/2005-04/071/content_2796900.htm,2006年元月20日最后一次访问。

〔7〕 参见王锡锌:"中国行政执法困境的个案解读",《法学研究》2005年第3期。

〔8〕 关于行政执法困境,王锡锌认为该"执法困境产生的根本症结在于政府立场和法律规则与民间现实需求之间的不协调,"因此"成本最小的解脱方案是政府重新调整甚至放弃其原有的立场。"相关具体内容参见王锡锌,同上注。

〔9〕 参见张维迎:"法律与社会规范",《比较》第11辑,中信出版社2004年版。

〔10〕 参见,Paul Mahoney and Chris Sanchirico, "Norms, Repeated Games, and the Role of Law", 2003, *California Law Review*, Vol. 91, 1280-1329. 其他的代表性成果包括 Robert Ellickson, 1991, *Order without Law, How neighbors settle disputes*. Cambridge, MA: Harvard University Press; James Coleman, 1990, *Foundations of Social Theory*, Cambrdge, Mass and London: Harvard University Press; Jon Elster, *The Cement of Society*, Cambridge: Cambridge University Press; Eric Posner, 2000, *Law and Social Norms*, Cambridge, MA: Harvard University Press; Richard McAdams, 1997, "The Origins, Development, and Regulation of Norms", *Michigan Law Review*, Vol. 96, 338;等。转引自张维迎,同上注,页158。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

执行——依赖于社会规范,”又由于燃放烟花爆竹是中国人千年以来形成的稳固的社会规范,北京市人大制定的“禁放令”在实际中“禁而不止”就是完全可以预见到的了。[11]

这是一个相当有说服力但却不完全的理论解释。实际上,习惯(或者不准确地说,社会规范)和正式法律之间的关系一直是法理学,甚至是经济学和社会哲学的一个核心命题,古希腊索福克勒斯的伟大悲剧《安提戈涅》早就隐含了这一张力(只不过在剧中安提戈涅声称她遵守的是“神定法”而已),[12]自然法(或“更高的法”)与实在法之间的冲突与矛盾也与之相关。虽然哈耶克从知识论和社会哲学的角度对这一关系进行了系统的阐述,但只有二十世纪五十年代以后迅猛发展的博弈论才以一套社会科学的语言对之进行了相当令人信服的解说。就非正式法律和正式法律的关系而言,重复博弈理论证明了交织紧密的群体能发展出一套最大化群体福利的社会规范,形成一些“无需法律的秩序”,[13]因此,埃里克森才声称“是规范,而不是法律规则,才是权利的根本来源。”[14]也因此,苏力才坚信埃里克森的研究“确立了民间法或民间规范是社会秩序之根本这样一个普遍性命题。”[15]进一步地,不仅是熟人社会,埃里克·波斯纳更是运用信号传递博弈分析和论证了基于合作的目的,人们在信息不充分的现代陌生人社会也仍然能发展出很多他们乐于遵守的社会规范。[16]

从这样简单的一个学术梳理中,我们可以发现习惯、规范和法律之间关系的复杂性和重要性,也可以发现自哈耶克以来很多对人类理性有着深刻反思的学者对洋洋自得的“立法”的警惕,对人类在长期社会生活中形成的习惯和规范的尊崇。用博弈论的话来说,这种习惯和规范是人们长期复杂互动行为的“纳什均衡解”,是一些和人们的利益“激励相容”因此人们乐于遵守的规则。也因此,我认为张维迎先生沿着这一学术脉络对“禁放令”及其效果的相关分析是强有力的(王锡锌就“禁放令”的分析在我看来也同样分享了这一学术前提),但问题仍然存在。其一,习惯或者社会规范就是这么不可动摇,人为的“立法”难道没有任何对之进行影响和纠正的可能吗?其二,具体到燃放烟花爆竹以及“禁放令”的功过,我们要问一问,中国人千年以来燃放烟花爆竹的行为真的是博弈论意义上的能够增进合作和最大化群体福利的社会规范吗?如果通过细致和有道理的理论分析分别得出了肯定的(就第二个问题而言)和否定的(就第一个问题而言)答案,不仅“禁放令”的出台可能就是有道理的;而且由于从逻辑层面抽掉了之前相关研究共享的学术前提,因而前面就“禁放令”做出的分析至少是不全面的,由此得出的结论自然也就不太稳靠。

本文就是一个运用博弈论和法律经济学的相关理论,对燃放烟花爆竹以及“禁放令”的是非功过进行深入讨论和分析的学术尝试。讨论的主题虽是“禁放”还是“限放”,但背后的道理和学术关注其实是一般性的,那就是我在另外一篇文章中明确提到过的,法律中心主义也好,规范中心主义也罢,在我看来都只是部分地认识和解释了我们身处其中的这个复杂世界的局部真理,因为法律和社会规范作为影响人们行为的制度规则本来就是相互影响、共同起作用的。——它们既互补,又替代!而真正有价值的学术研究就是要具体分析它们在什么时候互

---

〔11〕 相关的具体分析,详见张维迎,同上注〔9〕。

〔12〕 《安提戈涅》的文本参见罗念生:《罗念生全集》(第二卷)(埃斯库罗斯悲剧三种 索福克勒斯悲剧四种),世纪出版集团,上海人民出版社 2004 年版;对安提戈涅悲剧细致的理论解读,参见苏力:“自然法、家庭伦理和女权主义?——《安提戈涅》重新解读及其方法论意义”,《法制与社会发展》2005 年第 6 期。

〔13〕 参见罗伯特·埃里克森:《无需法律的秩序——邻人如何解决纠纷》,苏力译,中国政法大学出版社 2003 年版,特别是第十章。

〔14〕 埃里克森,同上注,页 63。

〔15〕 苏力:“研究真实世界中的法律”,载《无需法律的秩序》(译者序),中国政法大学出版社 2003 年版,页 9。

〔16〕 具体内容参见,埃里克·波斯纳:《法律与社会规范》,沈明译,中国政法大学出版社 2004 年版.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

补,又在什么时候替代。

本文包括六个部分。第一部分是在事实和理论的梳理之后提出问题;第二部分运用博弈论的思想论证燃放烟花爆竹不是法律和社会规范理论意义上的社会规范,而只是一种需要改变的集体习惯;第三部分借用科斯定理和史蒂芬·夏维尔的研究,分析对于存在“负外部性”的侵害或者潜在侵害行为是采用产权规则、责任规则还是行政规制(或者说立法)来解决;第四部分从烟花爆竹市场的供给和需求两方面分析燃放烟花爆竹为什么禁而不止;第五部分分析政府“禁改限”背后的无奈和可能潜在的问题。最后一部分是一些余论。

二、燃放烟花爆竹是社会规范吗?

首先应该区分一下习惯、社会规范和法律,特别是习惯和社会规范。在博弈论看来,只有那种能够最大化交织紧密群体的福利并能使得遵守它的每个成员的利益得以增进的社会规范,以及为了增进陌生人之间的合作而表现为各种信号传递均衡的社会规范才是社会秩序的根本,而只有建立在此基础上的正式法律才可能获得人们的遵从,在这个意义上,“民间法才是社会秩序之根本”(苏力语,这里的民间法其实就是各种社会规范)。但在以往的很多研究中,习惯和社会规范几乎是等同的,他们认为“风俗习惯是一切制定法之外的最重要的法律,”因为“习惯和惯例一般都是在比较长期的社会生活中,在各种现有的制约条件下通过人们的行为互动逐步形成的规范,——它是一种内生于社会的制度,可以说它们凝结了有关特定社会的环境特征,人的自然禀赋和人与人冲突及其解决的信息,是人们在重复博弈后形成的在日常生活中(当社会生活主要条件没有重大变化时)必须遵守的‘定式’。”[17]可以看出,这里的“定式”其实就是博弈论意义上的“纳什均衡解”,这里的“习惯和惯例”也就是建立在博弈论基础之上的法律和社会规范理论视野中的社会规范,我们平时说的“民间法”也只有在这样的意义上理解才有约束力和生命力。但习惯和社会规范之间是有本质区别的,虽然含糊一点或者不准确一点我们也可以把“习惯”和“规范”混用,而且在很多情况下不会产生太大的理解歧异,但从概念上明确二者的区分却很有必要。而且,这一区分对于我要探讨的燃放烟花爆竹习惯尤其重要。

习惯、社会规范和法律之间一个最重要的区别在于强制程度不一样。张维迎先生在其《法律与社会规范》一文的一个脚注里讨论了这个问题,他认为这三者的“强制程度用英文表述可能稍微清楚一些。习惯是 do it,社会规范是 ought do it 或者 ought not do it,法律就是 must do it 或者 mustn't do it,语气是不太一样的。”[18]而且不只是语气不一样,三者背后的制裁程度也是不一样的。习惯,不仅是个人习惯,也包括一些集体习惯,只是径直去做就是了,做还是不做不会受到来自他人或者国家强力的制裁;社会规范却与之有所不同,由于是人们在长期的社会交往互动过程中形成的行为规则,一个人不遵守社会规范肯定就会遭受相应的制裁和惩罚。虽然有很多集体习惯作为一种内生于社会的制度已经规则化和社会规范化了,但并不能因此认为习惯或者集体习惯就等同于社会规范,这是一个需要我们注意的问题;强制性法律规范的制裁力就更强了,由于背后是国家机器和合法暴力,一个人违背了法律必然受到法律的制裁已经是基本常识。

因此,由于“将社会规范和其他社会常规区分开来的要点是:违反了社会规范会招致惩

〔17〕 苏力:“当代中国立法中的习惯”,载《道路通向城市——转型中国的法治》,法律出版社 2004 年版,页 105。

〔18〕 参见张维迎,见前注〔9〕,特别是页 164 的第 1 个脚注。但由于法律规范有授权性规范、强制性规范和任意性规范之分,因此张维迎先生在此指出的 must do it 或者 mustn't do it 应该是指其中的强制性规范。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

罚,但这些惩罚是作为人们理性自利的结果而内在生发出来的。"[19] 从强制程度和制裁力的有无和大小我们应该就能清楚地区分哪些是习惯以及哪些是社会规范和法律。

运用这个标准,我们来考察一下中国人逢年过节喜欢燃放烟花爆竹这一集体习惯和传统民俗。"爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏。"王安石的这两句诗行恰当地表达和描述了中国人通过燃放烟花爆竹欢庆新年的心情。在传统的农耕社会和"前祛魅"时代,冬闲时期的春节是辛苦了一整年的人们有节制狂欢的由头,而最早发明了火药的中国人也把这一发明用在了增加节日喜庆气氛的烟花爆竹上,可以说烟花爆竹的燃放伴随了中国人漫长的农耕时代,在这个意义上,它是一种延续了千年之久的古老民俗。但这一民俗或者集体习惯是社会规范吗?我不知道古代的情形,而根据社会常识和我的一些观察,在当代的中国社会其实是一些人喜欢放而另一些人不喜欢放的,我并没有看到有谁因为逢年过节不放烟花爆竹而被其他人"嚼舌头"或被所在社群放逐或者孤立的,而那些喜欢燃放的人也不见得因此更加被周围的人尊重或者人们更愿意和他合作。因此,按照强制程度和制裁力的标准,燃放烟花爆竹并不是一种人们应当做什么的社会规范,它既不是埃里克森指出的那种能够最大化社群福利的重复博弈规范,也不是埃里克·波斯纳揭示的那种能够促进陌生人之间有效合作的信号传递规范。它仅仅是一种源自农耕社会的、延续了千年之久的、某些中国人的集体习惯罢了。

如果这一论证还不充分,张维迎先生在《法律与社会规范》中运用博弈论的相关理论详细探讨过法律和社会规范的三种重要功能:协调预期、提供激励和传递信息,以此为标准,我们也可以从另一个角度来分析燃放烟花爆竹行为的性质。这一论证其实相当简单,由于燃放烟花爆竹并不是人们相互交往过程中必须遵守的行动规则,或者说人们的燃放行为更多的是一种单方行为,而不是一种博弈或者策略行为,因此它既不能协调人们的预期,帮助人们选择最优的行为,或者"从多个符合社会效率的均衡中筛选出一个均衡";也不能激励人们采取有效率的行为,或者"将不符合社会效率的均衡转换为符合社会效率的均衡";更不能通过这种行为传递有效合作需要的当事人需支付成本的私人信息。[20] 因为,这一古老习俗并不是维护社会秩序的基本博弈规则。

因此,根据前面的分析和论证(我不敢说这一论证是全面的,但在我看来至少是充分的),燃放烟花爆竹这一被很多人视为"寄托了中国人的深厚感情和文化需要"的"不可替代"的传统民俗,只不过是某些中国人的集体习惯,而根本不是那些支持燃放的民众甚至学者们认为的是一种构成了正式法律之基础的社会规范。也因此,根据这一结论,那些认为"禁放令"由于违背了人们普遍认可的社会规范因而作用有限的研究是不太有道理的,至少是不完全的。而且退一万步说,即使燃放烟花爆竹行为在历史中曾经起到过类似于社会规范的作用或者在中国当代的某些地区还有一点规范的影子(这也只是一种可能,前者需要历史的考证,后者也需要细致的社会调查才能确定),这也不能是反对通过立法禁止燃放烟花爆竹的理由。因为如果该行为曾经是社会规范,那也只是"曾经",现在它已经不是了,因为"如果坚持历史唯物主义的观点,那么作为上层建筑之一部分的习惯一定会并总是会随着社会生产、生活方式的变化,随着社会制约条件的变化而不断流变。"[21] 社会规范当然也不例外;如果它在当代中国的某些地区还有一点规范的影子,那也只能说明中国各地区间的政治经济发展不平衡,规范和习惯的变迁还在缓慢地继续,这更是政策和立法可以"大显身手"的地方。政府并不需要在这些方面"置身事外"。也许很多学者要争辩说,既然规范一直在随着社会生活方式的变化而变

〔19〕 波斯纳,见前注〔16〕,页 10。

〔20〕 对此三个功能的详细分析,请参见张维迎,见前注〔9〕。

〔21〕 苏力,见前注〔17〕,页 106。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

化,规范自身的调整和演化就能适应社会,政府的干预甚至立法在这个意义上恐怕就有点多余了。但波斯纳法官已经相当犀利地指出了,"不论实用主义者多么欣赏达尔文,他们都承认进化是非目的论的,不能想当然地认为进化会导致合乎规范的诱人结果。"[22]因此,即使我们前面论证的结果为燃放烟花爆竹就是一种社会规范,法律(或者说立法)也不是完全没有对之进行调整和干预的空间,这是一个非常重要的理论命题,由于主题所限和篇幅的问题,我在此不予展开(以后有机会或许会另文讨论)。[23]

更进一步地,如果燃放习惯只是一种无论收益成本都能够内在化的,对其他人和社会都"无害"的集体习惯倒也罢了,即便它很顽固,我们兴许就随它去,不会去管它。但这些年来,燃放烟花爆竹引发的各种危害或者潜在危害已经使得无论是允许燃放还是禁放都引起了整个社会的关注和讨论,用米尔斯的话来说,这一话题已经成了当代中国"社会结构中的公共论题"了。由于"我们在各种特定环境中所经历的事情往往是由结构性的变化引起的",因此,一个这样的公共论题事实上"往往包含了制度安排中的某个危机,或是马克思主义者所说的'矛盾'或'对立'。"[24]

之所以存在"矛盾"或者"对立",根本原因在于当代中国的现代转型。[25] 在传统的农业社会,人们往往生活在一个个相对封闭和隔离的小村庄里,人烟也不是很稠密,在那样的环境下,逢年过节放放鞭炮喜庆喜庆没有什么问题,因为没有什么"外在性",[26]引起伤害和火灾的概率也都比较小。但自鸦片战争以来,中国开始了一场至今仍在继续的"前无古人,后无来者"的巨大的社会转型,按照一些学者的说法,"这是一个全面的秩序破坏和秩序重建,这是一个整体性的结构变迁,是略有夸张的'三千年未见之大变局'",[27]概括地说,这是一条迈向现代化、城市化的"历史不归路"。而以工商经济为基础的现代社会肯定就使得很多原来在农耕社会"不构成问题的现象成为了问题"(苏力语),燃放烟花爆竹就是其中之一。简言之,伴随着当代中国"不以人意志为转移"的现代转型,伴随着改革开放和市场经济在中国的确立,特别是伴随着近十年来快速的城市化进程(北京市的"禁放令"出台于1993年,未尝没有带着这一背景和时代变迁的烙印),这一在传统农业社会不构成问题的古老习俗在当今遭遇了挑战。就燃放烟花爆竹而言,米尔斯所说的"矛盾"或"对立"也只有在这个社会结构的变迁中才能够得以理解。由于对该传统习俗的坚持已经在现代化的城市生活中显示出了其破坏性的一面(现代城市往往建筑密集、人口稠密,因燃放烟花爆竹导致的火灾概率就比人烟稀少的乡村不知高出多少倍!),又由于在公共场所燃放烟花爆竹不是一个所有成本都能'内在化'的行为,它必然就具有可能影响他人的负外在

---

〔22〕 理查德·波斯纳:"凯尔森对哈耶克:实用主义、经济学和民主",载《法律、实用主义与民主》,凌斌、李国庆译,中国政法大学出版社2005年版,页325。

〔23〕 埃里克·波斯纳在其〈法律与社会规范〉一书中对此问题有详细的阐述和论断,在他看来,很多"自生自发"的社会规范其实是不利于社会整体福利的,它们是一些需要立法对之进行调整和影响的"坏均衡",但他同时也对这种影响的后果表示怀疑。对此问题,波斯纳并没有什么确定的结论和答案。具体内容参见波斯纳,见前注〔16〕,特别是第六章和第七章。

〔24〕 相关内容参见C·赖特·米尔斯:《社会学的想象力》,陈强、张永强译,三联书店2001年版,页7-9。

〔25〕 对现代化和中国法治之内在联系和各种"悖论"的细致分析,参见苏力:"现代化视野中的中国法治",载《道路通向城市——转型中国的法治》,见前注〔17〕。

〔26〕 "外在性"或者说"外部性"是现代经济学里面一个出现较晚但却越来越重要的概念。按照盛洪的归纳,迄今为止有三个较权威的定义,但我这里采纳盛洪的定义,即"当一个(或一些)人没有全部承担他的行动引起的成本或收益时,反过来说,有人承担了他人的行动引起的成本或收益时,就存在外部性。"参见盛洪:"外部性问题和制度创新",载《治大国若烹小鲜——关于政府的制度经济学》,上海三联书店2003年版,页22。

〔27〕 参见朱苏人:"法本质理论的接受与中国传统的'法'和'法治'",《比较法研究》1997年第2期。转引自苏力:"现代化视野中的中国法治",载《道路通向城市——转型中国的法治》,见前注〔17〕,页21。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

性——因而由政府出面制定禁令就有其正当性。

因此,即便是被很多人视为"不可替代"的古老习俗的集体习惯,只要它带来的问题不能被它自身的力量所解决,来自于政府的"外部侵扰"就是有一定道理的。波斯纳法官就指出了,"习惯作为社会规范的来源,有两个局限性需要特别强调。第一个局限是,——习惯常常支持对社会整体有害的合作活动。第二个局限在于,——习惯,是群龙无首的(相对于立法机关这样一个立法者,并没有任何的'立习惯者'),往往改变得非常缓慢。如果经济或其他社会实践在迅速地改变,习惯就常常跟不上步伐并且成为进步的拖累。"[28]燃放烟花爆竹的行为就是这样一个因存在"负外部性"和两种局限性而需要法律出面加以调整和改变的集体惯习或者习俗。

三、产权规则、责任规则还是行政规制

由于燃放烟花爆竹的习惯在快速城市化的当代中国可能会带来很多"负外部性",带来很多该习惯无法克服的潜在严重危害,更由于习俗的变迁是缓慢的,因此运用法律对之进行干预就是有道理的。在盛洪看来,"外部性问题的存在,反映了人类社会一个根深蒂固的矛盾,即个人理性和集体理性、个人最优和社会最优之间的不一致。"[29]而法律的一个作用就是通过各种制度的设计使得个人理性和集体理性、个人最优和社会最优尽可能一致,以此来解决现代社会越来越多的"外部性"问题。具体到燃放烟花爆竹,法律应该采用何种规则才能有效地解决这一个人最优和社会最优之间的不一致呢?

科斯在其著名的《社会成本问题》一文中探讨过"外部侵害"问题,与庇古不同,科斯天才地注意到了"权利的相互性"问题,"是允许甲损害乙,还是允许乙损害甲?关键在于避免较严重的损失。"[30]在此基础上,科斯指出"有必要知道损害方是否对引起的损害负责,因为没有这种权利的初始界定,就不存在权利转让和重新组合的市场交易。但是,如果定价制度的运行毫无成本,最终的结果(产值最大化)是不受法律状况影响的。"[31]这就是后来被斯蒂格勒总结为"科斯定理"的"原始版",或者"科斯第一定理"。由于现实世界交易成本无所不在,法律作为确定初始权利归属以确保产值最大化的作用才体现了出来,这是"科斯第一定理"合乎逻辑的推演,也就是著名的"产权规则"或者"科斯第二定理"。根据该定理,对于各种存在"负外部性"的侵害行为或者潜在侵害行为,法律可以以正式规则的方式宣布谁拥有权利,谁承担义务,但这种初始权利的配置必须以最大化社会福利为前提。[32] 通过拥有权利的个人与其他人之间的交涉甚至权利交易,法律实现了个人最优和社会最优的近似一致。

"在科斯的世界里,明确界定的产权(well - defined property rights)是唯一必要的激励机制,因为任何外部成本和外部收益都可以通过当事人的自愿协商内部化,个人最优就是社会最优,因而,产权规则(property rule)是实现社会效率的充分规则。"[33]但在复杂的现实世界里,"产权规则"虽重要却不充分和全面。如果交易的人数众多,或者信息不完全带来的交易成本太高,产权

〔28〕 波斯纳,见前注〔22〕,页 325 - 326。

〔29〕 盛洪,见前注〔26〕,页 22。

〔30〕 罗纳德·哈里·科斯:"社会成本问题",载《企业、市场与法律》,盛洪、陈郁译,上海三联书店 1990 年版,页 76。

〔31〕 科斯,同上注,页 83。

〔32〕 当然,这种初始权利的配置并不一定完全由法律制度来确定。埃里克森的《无需法律的秩序——邻人如何解决纠纷》一书就用夏斯塔县的经验材料和重复博弈的理论论证和指出了,交织紧密群体自发形成的一些社会规范也同样能够确定初始权利的配置和相应的一系列规则。具体内容参见,罗伯特·埃里克森:《无需法律的秩序——邻人如何解决纠纷》,苏力译,中国政法大学出版社 2003 年版。

〔33〕 张维迎:"作为激励机制的法律",载《信息、信任与法律》,三联书店 2003 年版,页 75。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

规则就解决不了个人最优和社会最优的矛盾,因为一个人不可能和未知的不特定多数人签定合同,也就不可能实现权利的交易和转移。比如,一个司机就不可能和所有行人以及其他司机签合同,一个人也不可能提前和所有可能伤害他的人签定合同,等等。因此,“责任规则”也就在这样的情形下有了运用的空间,如果说“产权规则”是一种事前的安排,那么“责任规则”就是一种通过事后责任的分配来“内部化个人的外部成本,诱导个人选择社会最优的行为。”[34] 如何确定既能够“补偿受害人实现社会公正”又能够“最小化社会成本实现社会效率”的“责任规则”是整个侵权法的核心,也是法律制度解决“外部性”问题又一个有力工具。[35]

但是“责任规则”也还不够。由于“侵权责任是私人性质的,它并不通过社会指令来运作,而是更为间接地通过危害发生后引起的损害赔偿行为所产生的威慑作用来运作。”[36] 对于那些有可能使公共安全或不特定多数人受到侵害的“外部性”行为,“责任规则”似乎就有点“无能为力”,而且当一个行为带来的损害太大,该行为人没有能力偿还的时候,“责任规则”也有点“尴尬”,在这种情形下,来自政府的行政规制或者立法就有其必要性了。史蒂芬·夏维尔1984年的一篇论文仔细地讨论和辨析了适用“责任规则”还是行政规制的四个决定性因素,其一是“私主体各方与规制当局在有关风险行为的知识上可能会存在差异”;其二是“私主体可能不具有支付全部数额的损害赔偿的能力”;其三是“当事方无须面对损害赔偿之诉威胁的几率”;其四是“在运用侵权体系或直接规制的时候,私主体或公众所引起的行政费用”。他的结论是,“对这四项决定因素的考察结果表明,其中两个一般性因素支持责任(行政费用和知识差异),而另外两个支持规制(不具备赔偿能力与逃避诉讼)。一个完备的解决风险控制问题的方案显然应当将责任和规制结合起来运用,对反映出两者重要性之差异的那些决定因素进行平衡。”[37]

因此,根据法律经济学的相关研究成果,我们发现对各种侵害他人或者潜在侵害他人的“负外部性”行为,法律可以采用“产权规则”、“责任规则”和行政规制(或者立法)加以调整和控制,通过规则的实施使得行为人的外部成本内在化从而实现个体理性和集体理性,个人最优和社会最优的统一。只不过究竟采用何种规则则需根据所解决问题的性质和特点灵活处理,这也是具体研究所要解决的问题。

有了这些理论储备,我们再来看法律应该如何看待和解决在当代社会有很大“负外部性”的燃放烟花爆竹行为。先来看“产权规则”。出于对私人意愿和自愿交换的尊重,也出于通过权利的初始确定促使社会福利增进的目的,我们可以简单地在法令中宣布人们有还是没有燃放烟花爆竹的权利。根据科斯定理,只要交易成本为零,权利不管配置给谁都不影响最终的社会福利最大化的结果,因为双方的权利交易能使得出价更高的一方获得该权利。但就燃放烟花爆竹而言,在交易成本不为零甚至还很高的现实世界里,权利不管配置给哪方都不可能达到社会福利最大化的目的。原因在于,一个不喜欢烟花爆竹的人不可能和周围所有拥有燃放权的人一一进行谈判,反之亦然,交易成本太高了,因此这种权利根本就不可能在人与人之间交

〔34〕 张维迎,同上注,页63。

〔35〕 对产权规则和责任规则的相关分析,还可以参见卡拉布雷西和梅拉米德的经典论文,Calabresi, Guido and A. Douglas Melamed (1972), “Property Rules, a Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral”, 85 *Harvard Law Review* 1089 – 1128. 该文的精简版已有中文译本,参见吉多·卡拉布雷西,道格拉斯·梅拉米德:“财产规则、责任规则与不可让渡性:‘大教堂’的一幅景观”,载《法律经济学文献精选》(唐纳德·威特曼编),凌斌译,法律出版社2006年版,页29 – 50。

〔36〕 See, Steven Shavell (1984), “Liability for Harm versus Regulation of Safety”, 13 *Journal of Legal Studies* 357 – 374. 其精简版也有了中译本,参见史蒂芬·夏维尔:“损害赔偿责任抑或安全规制”,载《法律经济学文献精选》(唐纳德·威特曼编),罗玥译,法律出版社2006年版,页92。

〔37〕 夏维尔,同上注,页93 – 99。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

换和转移。另外还有"搭便车"的问题,由于"'安全'对社区中每一个成员来说都是公共产品。因此用市场的方法'购买安全'就有可能失败,因为'安全'一旦被提供,对社区的所有成员都是一样的,但不同的成员对安全的需求是不同的,并且有人还会采取'搭便车'的行为:不为'安全'付费也会享受安全的好处。"[38]基于这两个原因,即便"产权规则"有诸多好处,但对于燃放烟花爆竹这样一个可能危及社区安全的"负外部性"行为而言,它却是无效的。

"责任规则"因此就进入了我们的视野,对于燃放行为而言,什么样的责任规则才能诱导行为人的个体理性和整个社会的集体理性相一致呢?由于燃放更多的是一种单方行为,或者燃放事故发生的概率和带来的损失只与燃放人的预防行为有关,而与受害人的行为无关,除去没有效率的无责任规则,理论上讲严格责任规则和过失责任规则都是有效的。但"严格责任规则和过失责任规则的等价性是有条件的。过失责任规则的有效性要求立法部门或者法院对成本曲线有完全的知识,因而法定标准是帕累托最优的,同时也要求法院事后能够观察到加害人的实际行动。"[39]一旦法定标准偏离了帕累托最优(由于现实世界中信息的限制,这种情况其实是普遍的),或者法院事后无法观察到加害人的预防行为,严格责任规则就更为有效。具体到燃放行为,由于法律不可能制定一套最优的惩罚标准,而且法院不可能也没有必要去了解燃放人是否是故意的,只要发生了侵害事故,加害人就要承担责任,因此,严格责任规则就是一个有效的并在实际中被运用的标准。

但对于燃放可能带来的事故和伤害而言,单单是严格责任规则可能还远远不够。夏维尔在其《损害赔偿责任抑或安全规制》一文中就明确指出了,当事人不具备赔偿能力以及面临诉讼的几率极小这两个因素就有可能使得责任规则无效;而且即使是导致责任规则更可取的"私人主体拥有更多的有关风险行为之知识"方面,也不是绝对的,因为"在处理许多有关健康和环境的风险时,规制当局可能掌握更好的途径去获得(或者更有能力去评估)相关的医学、流行病学和生态学的知识。"[40]夏维尔由此认定在"规制在行政费用和知识差异上的劣势问题并不大"的情况下,如果"责任主体更有可能不具备赔偿能力,或者更加可能逃避对其造成的损害所进行的调查和诉讼,"政府的安全规制就更可行。[41]

具体到燃放行为,由于一个人或者一个家庭的财产有限,当事人很有可能对燃放带来的损害(比如人身伤害或者引发的火灾等)赔偿不足,[42]这是一个强有力的支持政府出面干预的理由。[43] 另外,虽然不像对生态环境的破坏是缓慢的,也不像有问题的药品带来的损害是分散在各地的(由于大家都想"搭便车",因此药厂就很有可能逃避了诉讼),但引起了损害结果的燃放人也很有可能逃避对其的诉讼,特别是在引发了火灾的情形下(因为很难查清究竟是谁的燃放引发了火灾),因此,这也是一个支持政府出面规制的理由。最后,政府对燃放可能带

〔38〕 盛洪,见前注〔26〕,页 28。虽然盛洪在此处讨论的是国防安全问题,但对于我在这里讨论的由于燃放烟花爆竹而带来的社区安全问题,道理其实是一样的。

〔39〕 张维迎,见前注〔33〕,页 97。

〔40〕 夏维尔,见前注〔36〕,页 103 - 104。

〔41〕 夏维尔,见前注〔36〕,页 105。

〔42〕 也因此在审议《北京市烟花爆竹安全管理条例(草案)》时,某人大常委会委员的建议就不太具有可行性,他认为"谁放谁承担责任,——该他承担责任的时候,哪怕令他倾家荡产我们都不要给予同情,你炸死了三个人该赔二百万就赔二百万。"话是可以这样说,但他赔得起吗?

〔43〕 对此,有一个值得考虑的反驳意见,即个人完全可以通过购买保险内化这一成本而无需政府的介入。我同意这一反驳意见提出的某种可能性,但认为就燃放烟花爆竹而言,这一建议可能并没有多少可行性。原因不仅在于保险公司可能不会为这样一个燃放行为设置一个新险种(从成本——收益和信息可获得性的角度看,由于不可能知道某人燃放是否合理和小心,由于新险种宣传的成本,这一设置可能不太经济),更在于即使有了这样一个险种,人们可能也不太愿意为自己没有认识到或低估的风险花钱购买。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

来的危险性的认识可能比普通人要强。根据 Amos Tversky 和 Daniel Kahneman 的开创性研究,人们经常使用的“经验法则,例如‘可得性启发’——某个事件的频率是通过判断回想这类事件的其他例子的容易程度来估计的(这样的例子如何‘可得’)——会把我们引向错误的结论。”[44] 而行为主义经济学家 Christin Jolls ,Cass R. Suntein 和 Richard H. Thaler(合称 JST)认为“‘可得性启发’会导致过度规范和规范不足,人们有时(尽管不总是)低估了低概率或不显著事件的可能性,因为这些威胁没有显示在人们的‘雷达屏幕’上;——但是当一个特定的威胁,即使是一个不太可能发生的事件,被人们看见时,——那么对规则的需求就产生了。”[45] 因此,当人们“没有足够能力准确地加工他们拥有的与自己风险有关的信息时”,过度乐观(大多数人相信他们对负面结果的风险远低于普通人)结合显著性影响(某些危害不是非常显著)就会使得人们严重地低估风险。[46]

根据行为法经济学的这个研究结果,我们发现大多数人认为燃放烟花爆竹的风险性不大这样一个认识是有严重偏差的,因为人们总是低估自己没有经历过或者亲眼看见过的危险,在这个意义上,政府根据相关的统计数据和社会整体考虑对该风险的认识和知识会比一般人准确得多。[47] 因此,普通人赔偿能力不足、面临诉讼的概率较低再加上对燃放行为风险性的严重低估就是政府通过以立法形式表现出来的行政规制手段禁止燃放烟花爆竹的理论根据。

综上所述,对于具有“负外部性”并且可能带来严重损害的燃放烟花爆竹行为,我的结论是应当采取行政规制为主,严格责任规则为辅的解决之道。

四、为什么禁而不止?——烟花爆竹的需求和供给分析

前面的理论分析其实已经论证了在快速城市化的当代中国,由政府出面制定“禁放令”的合理性和现实必要性,因此,1993 年北京市人大制定的“禁放令”就是有道理的(虽然当时的立法者可能根本没有这些基于经济学理论上的考虑,他们更关心民众的呼声和“保障国家、集体财产和公民人身财产安全”)。但为什么该法令在实际运行中却屡屡遭遇到“禁而不止”,或者被有的学者概括为“对制度的制度化拒斥”呢?[48]

---

〔44〕 See, Amos Tversky & Daniel Kahneman, “Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases”, *Judgment Under Uncertainty* (Daniel Kahneman, Paul Slovic & Amos Tversky ed. , 1982) 转引自,克里斯蒂·朱斯(Christin Jolls)、凯斯·R·孙斯坦(Cass R. Suntein)、理查德·西拉(Richard H. Thaler):“法和经济学的行为学方法”,王卫东、董颖琼译,《北大法律评论》第 6 卷第 3 辑,页 463。

〔45〕 同上注,页 484。对 JST 行为法经济学的评论,还可参见理查德·波斯纳:“行为主义法律经济学”,《法律理论的前沿》,武欣,凌斌译,中国政法大学出版社 2003 年版,页 260 - 298。

〔46〕 朱斯、孙斯坦、西拉,同上注〔44〕,页 493。

〔47〕 虽然政府可以通过告知的方式将这些风险传达给民众,按照一般的说法,风险估计也会随着信息的增多而变化。但依我们自己的切身感受,在中国,这种警示性的告知从来都有而且遍布大小社区,甚至偏远乡村,不过人们即使接受了这样的信息可能也不会改变自己可能遭遇这种风险的估计。否则只需告知就万事大吉了,哪需要什么“禁放令”和责任规则。

〔48〕 王锡锌在“中国行政执法困境中的个案解读”一文中,就借用美国著名社会学家默顿的这一概念说明“禁放令”在中国实际中的尴尬和困局,“假如大规模违规行为的存在构成了一个事实,并且基本上很难受到制裁”,而这就很有可能“形成所谓‘对制度的性规则的制度化违背’。在这种情况下,一种非正式制度(潜规则)生成了,并取代了正式制度,正式的规则或制度名存实亡,实际上等于被废止。”但对这一判断有所保留,因为按照默顿的概念,“对制度的制度化拒斥”的成立有两个很重要的因素:“被大多数人所采纳”和“有相当完备的社会组织机制”,而我认为并不是大多数中国老百姓都抗拒这个法令而且也没有证据说这种对“禁放令”的违背有什么组织机制,因此,我认为这一判断至少是有点夸大的。参见王锡锌,见前注〔7〕,页 37;关于“对制度的制度化拒斥”,参见罗伯特·默顿:《社会研究和社会政策》,林聚仁译,三联书店 2001 年版。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

根据已有的研究,该法令之所以"禁而不止",之所以不被老百姓接受,最主要的原因在于"禁止燃放烟花爆竹的规定与中国人'逢年过节喜庆应该放鞭炮'的社会规范是不一致的,"[49]因此大量社会成员对这一"法律规则所代表的政府立场本身就缺乏足够的认同"。[50]在他们看来,制定这一想改变甚至消灭人们所珍视的传统习俗的法律是没有用的,用埃里克森的话来说,那些对"促进非正式合作的社会条件缺乏眼力"的立法者只不过又以实际行动造就了一个"法律更多但秩序更少的世界"罢了。[51] 这些解释虽有一定道理,但却很不完全。根据本文第二部分的分析,"逢年过节喜庆应该放鞭炮"根本就不是构成社会支撑性力量和正式法律之基础的社会规范,而只是中国人从农耕社会延续至今的一种集体习惯,而且在高速发展的当今社会已经带来了相当大的"负外部性"。因此,"禁放令""禁而不止"的原因恐怕就不仅仅是人们不尊崇一个违背了他们日常行为规则的法律这么简单了。

在我看来,由于以往的研究太多强调"禁放令"的不合理,强调民众对该法令违背和"不遵从"的正当性,先不说这一判断的理论前提有问题,即使其道理说得通,它也仅仅看到了人们之所以燃放烟花爆竹的一个方面,即燃放行为的需求方面。但经济学的常识告诉我们,只有同时存在供给和需求,才能成其为一个现实的市场,或者说,如果没有烟花爆竹的生产和销售,民众即使有强烈的燃放需求也是不可能实现的。因此,讨论"禁放令"为什么"禁而不止"就必须从烟花爆竹市场的供给和需求两个方面入手。

先来看烟花爆竹市场的供给方面。相对于很多劳动密集、资本密集以及技术密集的行业而言,由于生产工艺简单,容易掌握和操作,烟花爆竹行业的进入门槛非常低。很多家庭式的小作坊只需要几百元资金就可以开始生产,再加上生产烟花爆竹的所有原材料不仅便宜而且很容易买到,生产出来的产品又可以卖一个不错的价格,因此,对于很多没有技术、资金、专业知识和信息又想发财的普通人,特别是农村人而言,这是一个相当不错的致富选择。[52] 也因此,烟花爆竹生产源头上的供给就有了相当的保障,这是生产方面。另外,销售环节的暴利也是烟花爆竹供给旺盛的原因,因此,极低的行业进入门槛和暴利的存在使得烟花爆竹的供给非常充足,不仅如此,暴利还导致了很多违法的生产、运输和销售,这是"禁放令"禁而不止的一个很重要的原因。

还有一个不得不指出的细节。以往的研究都认为,执法人员对许多燃放烟花爆竹的行为"睁一只眼,闭一只眼"或者"袖手旁观"的原因在于他们也不认同"禁放令"体现的政府立场,不愿意破坏人们过年的喜庆劲儿,[53]我承认这一解释的合理性,但认为除了这一理由,"执法不力"恐怕还有其他可能的原因,那就是为了保障获取暴利的持续性,生产,特别是销售烟花爆竹的商人很有可能"贿赂"执法者从而达到与之"合谋"的目的。这只是一个猜测,并没有实

〔49〕 张维迎,见前注〔9〕,页 162。

〔50〕 王锡锌,见前注〔7〕,页 38。在一篇讨论民间收债的文章里,徐昕也谈到了法律为什么"禁而不止"的问题,就民间收债而言,他总结出了四点原因:民间收债源于市场需求而自发地产生;国家对民间收债的惩罚承诺实际上是不可置信的;人们的守法动机主要来自道德以及弱势个人或组织寻求合作导致对民间收债的需求。参见徐昕:"国家的态度——民间收债和私力救济的表达和实践",《论私力救济》,中国政法大学出版社 2005 年版,页 236 - 239。关于国家法和民间法,更早的文献参见苏力:"法律规避和法律多元","再论法律规避",载《法治及其本土资源》,中国政法大学出版社 1996 年版,页 41 - 74。

〔51〕 罗伯特·埃里克森:《无需法律的秩序——邻人如何解决纠纷》,苏力译,中国政法大学出版社 2003 年版,页 354。

〔52〕 市面上出售的烟花爆竹基本上都是来自很多经济不太发达的落后地区,也是一个明证,即使是非常有名的浏阳花炮(湖南省浏阳县本身就是比较落后的地区),它的生产厂家也往往是那些没有规模化生产的小作坊。之所以在落后地区生产的另一个原因在于该行业的危险性,经济发达的地区也不愿意生产,甚至很多大城市禁止在其城区生产这类产品。

〔53〕 参见张维迎,见前注〔9〕;王锡锌,见前注〔7〕。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

际证据,但根据人都是自我利益最大化的理性人的经济学假设,根据斯蒂格勒的"俘虏"理论,[54]这却是一个有道理的猜测。因此,从烟花爆竹的供给方面看,"禁而不止"可能还和执法人员与不法商人的勾结有关。

再看需求和消费方面。12年前,由于烟花爆竹给北京带来的危害很大,[55]正是老百姓的呼吁导致了"禁放令"的出台,可以说那个时候老百姓主动放弃了自己的这一需求。但时间过去了12年,为什么民众燃放烟花爆竹的需求又越来越高了呢?是像有些网友说的民族文化传统一种"'不以人们意志为转移'的迅速回归"吗?问题恐怕没有这么简单。在我看来,"禁放令"遭遇挑战最根本的原因就在于从农耕社会延续至今的逢年过节燃放烟花爆竹这一传统习俗太过强大和顽固了。坚持传统习俗本身无可厚非,甚至有时还值得提倡,但是我们却不能把"传统"绝对化,关键是要权衡坚持传统可能带来的利弊。我前面的分析其实已经论证在传统农耕社会利大弊少、没有什么"负外部性"的燃放习俗在快速现代化、城市化的当代中国已经带来了很多潜在的危害,坚持这一传统的好处可能已经远远小于其带来的坏处,[56]用埃里克·波斯纳的话来说,"这种习俗的持续时间已经远远超过了它丧失价值的那一时刻——如果它曾经真的有过什么价值的话。"[57]但由于中国快速现代化、城市化的历史才仅仅几十年,甚至十几年,而中国几千年的农耕社会和燃放烟花爆竹的历史已经使得这一习俗深深渗透到中国人的血脉甚至基因里去了。因此,我们可以说,在中国社会(特别是大中城市)的"硬件"都已经或多或少地现代化和城市化了的同时,[58]很多中国人的思想和行为方式却仍然还停留在过去的农耕时代。这是一个"悖论",但却是一个不得不承认的现实。也因此,才好理解人们在燃放烟花爆竹问题上态度和倾向的反复,才有民众"顶风作案","禁放令"禁而不止的情况出现。在这个意义上,集体习惯的改变需要时间,更需要一些能从既有的行为均衡中开拓出一条新路,带领人们走向更有效率的行为均衡的"规范创业者",不管它是政府,媒体,还是一些极具魅力的个人!

除了这个最主要的原因,人们屡屡挑战"禁放令"可能还在于:1.执法力度不够使得人们不太清楚政府真正的态度。就像王锡锌指出的那样,违规行为"基本上很难受到制裁,这些事实很快会成为'公共知识',通过学习过程,参与者的违规行为将可能在更大的时空范围内展开。"而中国人普遍都有的"法不责众"的心理就更助长了人们违法的冲动;2.在和平时代,面对禁止但执行不是很严厉的法律,人们往往希望获得一种"犯禁的快乐"。基于日常的经验和观察,可以猜测这种"犯禁的快乐"对于生活越来越刻板无趣的现代人而言诱惑非常大,更不

〔54〕 参见乔治·斯蒂格勒:《斯蒂格勒论文精粹》,库尔特·勒布、托马斯·盖尔·穆尔编,吴珠华译,商务印书馆1999年版。

〔55〕 在张维迎先生文中的一个数据表中,我们可以看到1993年因烟花爆竹导致的伤亡数和火灾都是所有年份中最高的,这可能是"禁放令"出台的一个原因吧。参见张维迎,见前注〔9〕,页161。

〔56〕 因此,运用成本——收益的方法,我们发现那些将烟花爆竹与汽车相类比的观点是站不住脚的,因为汽车虽然也带来一些问题(比如车祸),但它带来的收益是远远大于其成本的,可以说汽车就是现代社会的标志之一和必需品,离了它就无法运作;而燃放烟花爆竹的习俗其实是和现代社会格格不入的,其在当代社会的潜在危害已经超过了它的好处(增加一点热闹的过年气氛),而且它并不是人们的必需品,不放烟花爆竹也没什么大不了,找一些替代的过年方式就行了。当然,你也可以批评我的这一判断太过武断,有现代化意识形态的倾向,而且也不能以现代化为由否认所有私人实践。我同意私人实践是重要的,但所有的私人实践其实都是在一定历史的和现实的制约条件下进行的,中国当前快速的城市化就是这样一个不得不考虑的背景和制约条件。因此,我在此处,甚至全文的分析和判断其实只是指出了一种现实,指出了在变化的社会条件下应该怎样处理凸现出来的问题,而并不是什么现代化意识形态。

〔57〕 波斯纳:"效率与分配正义",见前注〔16〕,页260。

〔58〕 之所以这么频繁地提到"现代化"和"城市化",并不是对之不加反思并且将它作为中国必然要走的一条道路加以接受(这只是一种肤浅的"单线进化论"),而只是表述一个事实而已。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

要说这还是一种相对安全的“犯禁”了;3. 人们的消费习惯在短期内可能并不容易改变。在很长一段时间里,人们已经养成了逢年过节燃放烟花爆竹的习惯,这一消费习惯虽然因“禁放令”的出台而受到抑制但并没有消亡,只要实际上的法律环境有所松动,老百姓可能就会恢复这一习惯;最后,套用 Tversky 和 Kahneman 的“期望理论”——人们往往对失去的东西赋值更高——我们可以说,“禁放令”使得人们对失去的燃放烟花爆竹的权利看得比拥有它的时候更重了,这其实可以作为近年来这一传统习俗强烈“反弹”的一个不完全但却有启发性的解释。[59]

从以上对烟花爆竹市场需求和供给两方面的分析,我们可以发现“禁放令”禁而不止的原因并不像很多人想象的那样简单,而是人们追求利益的“原始冲动”和当代中国社会转型这个大背景下各种“矛盾”和“张力”的复杂综合。因此,如同米尔斯所说,“由于我们所置身的制度变得更为庞杂,彼此间的联系更为复杂,——要想对社会结构的观念有清楚的意识并敏锐地运用它,就要能在大量不同的环境中捕捉它们彼此间的联系。”而要做到这一点,我们就必须具备一种“社会学的想象力”。[60] 这是一种理解现代社会各种复杂联系的必要能力,也是我们讨论“禁”还是“不禁”这样一个看似简单实则复杂之问题的必要态度。

五、“禁改限”的无奈以及潜在的问题

根据前文的分析,北京市 1993 年制定的“禁放令”其实是一个既符合当时“民意”又符合社会发展趋势并且在实践中有着良好效果的法令,据有关统计,“从 1993 年 12 月至 2002 年 1 月间,因燃放烟花爆竹致伤人数平均值下降了 46%,禁放区因燃放烟花爆竹引起的火灾平均值下降了 50%,除夕夜城八区环境噪声平均值下降了 33%,烟花爆竹销售量平均值下降了 40%。”[61] 京城老百姓也享受了好些年安静祥和安全的春节。但为什么这样一个没有多大问题的法规却遭遇了被修改和废止的命运呢?

其实,“禁改限”的背后是北京市政府和北京市人大的诸多无奈。1993 年的“禁放令”是在人民群众的强烈呼吁下制定的,代表了当时的“民意”(83985 份市民意见调查表中 84.6% 赞成禁放烟花爆竹,几百名人大代表提议立法就是明证),但 12 年过去了,民意悄悄地发生了变化(2005 年北京市人大收回的 57431 份市民意见中,赞成适度放开的占了 59.6%),[62] 如果考虑“执政为民”和“立法民主”,法令要不要改? 近年来违规的民众有不断上升之势,执法成本也越来越大,原来在北京影响下“禁放”的城市中已有 108 个开始有限解禁,北京应不应该顺应潮流,也来个“禁改限”呢? 最后,在“以人为本”,尊重多数人意见以及减少执法成本的考虑和权衡下,北京市人大于 2005 年 9 月 9 日通过了新的“限放令”,废止实施了 12 年的“禁放令”。

这是一些看似很有道理的理由,但却经不起仔细推敲。首先而且最重要的,法律的“立”或“废”并不能仅仅依据多数人的意见。如果一个立法的有效与否要完全依赖于该法律是否

〔59〕 Tversky 和 Kahneman“期望理论”,参见,Amos Tversky & Daniel Kahneman, “Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk”, 47 *Econometrica* 263 (1979).

〔60〕 米尔斯,见前注〔24〕,页 9。

〔61〕 资料来源:“年节议‘禁放’:政府的尴尬与出路”(冯玉军),http://www.civillaw.com.cn/weizhang/ · id = 20908. 2006 年元月 19 日最后一次访问。

〔62〕 资料来源:“北京市人民代表大会内务司法委员会关于《北京市烟花爆竹安全管理条例(草案)》的审议意见报告”

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

真正体现了民意(或者以是否体现民意作为"良法""恶法"的区分标准),那么简单的"多数民主"就能主宰一个法律的"立"与"废",但历史的教训却让我们知道了"多数人的暴政",[63]经济学的常识也让我们知晓了集体行动的"非理性"逻辑,[64]因此,"顺应民意"并不完全是立法的目的。更吊诡的是,就燃放烟花爆竹而言,如果用"民意"作标准,我们就很难说2005年的"禁改限"就一定比1993年的"禁放令"更民主,更顺应民意,因为从简单的百分比来看,当时主张"禁放"的民众比现在主张"解禁"的民众在被调查人群中的比例更高。[65] 因此,"民意"虽然重要,却不应该成为一个法律"立"与"废"的决定性因素。因为,我们都知道"民意如水"的道理。而且公共选择理论和宪政经济学的研究成果已经论证了少数服从多数并不总是有效的,也并不总是合理的,而且多数在很多时候并不一定有力量。[66]

具体到"禁放令","禁"还是"不禁"背后其实是一部分民众要求安静安全的权利和另一部分民众要求声响娱乐的权利之争,不能说51%的民众要求声响娱乐的权利就一定大于49%的民众要求安静安全的权利,因此"民意"之争背后其实是两种权利或者两种自由的"拉锯战"。而根据《宪法》第51条,"中华人民共和国公民在行使自由和权利的时候,不得损害国家的、社会的、集体的利益和其他公民的合法的自由和权利,"我们似乎有理由认为要求安静安全的权利其实是大过要求声响娱乐的权利的。但现实中往往是"爱哭的孩子有奶吃",少数人的声音很有可能由于其情绪激烈,"叫得厉害"而被当局和立法者所采纳。因此,这个看似最强有力的理由其实并不那么强有力。

其次,违规人数增多和执法成本上升确实是一个废止"禁放令"的现实理由,但"禁改限"以后,违规人数和执法成本就真的如同立法者所愿能大幅度下降吗?这个问题我先卖个关子,这里暂不展开讨论;最后,其他城市纷纷解禁也并不是北京必须"解禁"的依据,一个城市的立法者应该根据所在城市的情况制定相关法规,而不能"一窝蜂"地"随大流"。[67]

---

〔63〕 我们都知道古希腊最民主的雅典城邦却处死了最智慧的苏格拉底,剥夺了他自由言论的自由,在这个例子中,我们可以夸张地说"民主杀死了自由"。中国的"文化大革命"其实也是一种大众民主的实验,但最后的教训恐怕任何对中国当代历史有所了解的人都不应该忘记。

〔64〕 参见曼瑟尔·奥尔森:《集体行动的逻辑》,陈郁、郭宇峰、李崇新译,上海三联书店,上海人民出版社1995年版,特别是第一章和第二章。

〔65〕 有文章称:"在1993年立法之初,北京市人大常委会于1993年9月对北京市城、近郊八个区发放了83985张市民调查表,共回收80592张,其中赞成禁放者68155人,占84.6%;反对禁放者10662人,占13.2%;态度不明者1775人,占2.2%。参见北京市人大常委会《内务司法简报》。参见冯玉军:"年节议'禁放':政府的尴尬与出路",http://www.civillaw.com.cn/weizhang/·id=20908,2006年元月20日最后一次访问。与之相对应的,2005年5月16日《北京市烟花爆竹安全管理规定(草案)》上网征集意见,在半个月的征集意见中,共有网友发表意见969条,其中反对"解禁"的有485条,约占50%,明确赞成解禁的意见共290条,约占30%,还有194条针对禁放提出各种设想和建议的,占20%。

〔66〕 参见盛洪:"经济学透视下的民主——谈谈有关公共选择的经济理论",载《治大国若烹小鲜——关于政府的制度经济学》,见前注〔26〕,页92-115。宪政经济学和公共选择经济学的相关文献,可以参见,Arrow, K. J., *Social and Individual Values*, John Wilsy & Sons, Inc; Buchanan, J. M. and Tullock, G. (1962), *The Calculus of Consent*, Ann Arbor: University Press; Buchanan, J. M and Brennan, H. G. (1985), *The Reason of Rules*, Cambridge: Cambridge University Press; Olson, M. (1982), *The Rise and Decline of Nations*, Yale University Press; 詹姆斯·布坎南:《自由、市场与国家》,上海三联书店1989年版;奥尔森,见前注〔64〕;等等。

〔67〕 在这一点上,兰州市政府和人大就做得比较好,虽然民众要求"解禁"的声音很高,但"常委会组成人员认为,传统的好的习俗应当弘扬光大,但传统习俗不符合现代文明的部分也要摒弃。周边城市相继解禁和有些舆论的观点不能成为解禁的主要理由,尤其是当传统习俗与人们的生存环境、生活质量发生冲突的时候,应该权衡利弊,从本地实际出发选择扬弃。——兰州市城区空间相对狭小,没有可供集中燃放的地段。传统的燃放习俗就是在家庭院落燃放,群众不愿意兴师动众去燃放地段燃放。一旦"限放",销售烟花爆竹将由非法变为合法,销售渠道口子一开,就可能造成燃放烟花爆竹的全面"解禁"。"最后,人大没有通过修改"禁放令"的法规。资料来源:"兰州,'禁改限'未获人大通过",http://eservice.digilib.sh.cn/jbzx/rbjb_details.asp·dbid=3975. 2006年元月20日最后一次访问。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

由此,我们看到北京市人大"禁改限"的依据并不是很充分的,只是一种安抚民众的"权宜之计"和"无奈之举"。但我们同时也看到,对政府和人大而言,"禁改限"其实还是有收益的,这收益不仅体现在顺应了"民意",体现了政府"执政为民"的诚意和人大"从善如流"、"立法民主"的进步,因而赢得了民心,维护了安定团结的大好局面;还在于他们认为此举既尊重了传统文化和民俗又维护了法律的脸面。因此,虽然在立法过程中有分歧,这一修改还是及时和合理的。

除此之外,可能还有一个推动法令修改的重要因素值得我们考虑,那就是因"禁改限"而获得重大利益的供销社系统。虽然在《北京市烟花爆竹安全管理规定》中我们根本看不到它的身影,但事实上可能正是它在背后促进和推动了"禁改限"的出台。之所以如此推测,原因在于"禁改限"后,建立于计划经济时代而在当前日渐式微的供销社系统"咸鱼翻身"般地在烟花爆竹专营中独揽了货源采购、合同控制、运输、仓储、配送和所有相关人员培训的权力。这其实是为一家不景气的国有商业企业人为制造了一种有大量收益的垄断权。[68] 基于立法中的利益集团理论,我们可以有道理地猜测供销社系统很有可能就是推动"禁改限"尽快出台的那一只"有形之手"。

不过判断一个法令合不合理,前面的那些理由恐怕远远不够,而且即便有供销社系统这一强劲的利益集团在背后推动,我们也不能仅仅因为这一理由就否定"禁改限"。我们需要考虑的是可能的现实后果。因此,出于一种"后果主义"的考虑和一点经济学、社会学的眼光,我想指出"禁改限"后可能潜在的五个问题,如果以后的实践证明我的担心多余了或者只是"杞人忧天",如果北京市政府有魄力和能力解决我提出的诸多问题,这一"禁改限"的法规可能才真正称得上合理和有效。

第一个问题,"限放令"规定的许可证制度可能会在实际中起一个"造租"的作用。《北京市烟花爆竹安全管理规定》第 7 条规定:"本市对销售、运输烟花爆竹依法实行许可制度。"并且在第 8 条和第 9 条具体规定了安全生产监督管理部门和公安机关分别是销售、储存和运输的发证机关。[69] 这三条规定看起来没有什么问题,也是加强烟花爆竹管理的必须手段,但只要有点经济学头脑的人都能透过这些堂皇的制度看到未来各种"权力寻租"的可能,在某种程度上,这一许可制度就是一个"造租"场。由于现实生活中每年办理"爆竹销售许可证"就要一万多元,该立法其实硬生生地为相关行政机关增添了一个收入不菲的权力,考虑到烟花爆竹安全管理的重要性,权衡利弊后,我们也可以认同和接受这一权力以及附带而来的大量收入。但经济学"自利人"假定和"寻租"理论告诉我们,这一意在限制市场进入的制度也许只是为某些执法人员的"徇私舞弊"提供了可能性,为大量的"权钱交易"提供了舞台,该制度意图的烟花爆竹的安全管理很有可能打折扣。退一步说,即使所有的执法人员都大公无私,该制度实施的有效性也要打个问号,因为办证的费用不菲,很多销售者很有可能不会去办理,更不要说那些本来就是违法生产和销售的"不法商人"了。[70] 不过,这样一个具有"造租"功能的许可证制

〔68〕 资料来源:《关于研究部署本市烟花爆竹专营有关工作的会议记要》,北京市人民政府办公厅,2005 年 10 月 28 日。从这个《记要》里我们还可以看到一些计划经济时代的痕迹,即如果市供销总社供货资金不足,由国资委和市财政局想办法解决。一个纯商业行为居然能劳动政府机关,这也只有放在国家统管一切的计划经济思维里才能理解。由此,我们似乎可以窥见"禁改限"背后"秘而不宣"的统制经济的有限回归。

〔69〕 具体参见:《北京市烟花爆竹管理规定》,资料来源:http://www.bj.xinhuanet.com/bjpd_bjzq/2005-10/01/content_5270124.htm,2006 年元月 20 日最后一次访问。

〔70〕 在"限放令"制定之前,北京郊县的烟花爆竹其实早就实行了许可证制度,但实际上就有很多人根本不去办,只要有关系、被查处的可能性也比较小。参见:"北京禁放令修订案年内提交 是否解禁看市民意见"(之现状调查),http://news.china.com/zh_cn/domestic/945/20050407/12223382_1.html。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

度之是非功过可能还需要在未来的具体实践中得以验证,我在这里的讨论只不过基于经济学理论的一点质疑罢了。

第二是几个管理部门的有效衔接问题。原来的“禁放令”只规定公安机关是禁止燃放烟花爆竹工作的主管机关,权力和责任的指向都相当清楚,但新的法规增加了很多相关的行政管理机关和执法组织。该法第3条第2款就规定,“市和区、县应当建立由公安、工商行政管理、安全生产监督管理、质量技术监督、交通、市政管理等行政部门和城市管理综合执法组织组成的烟花爆竹管理协调工作机制,按照职责分工,各负其责。”初看起来,这一规定显示了对烟花爆竹安全管理的重视,应该比老规定有效。但我认为新规定的有效是建立在各行政管理部门认真履行自己的职责,各部门之间的有效衔接和事后不推诿责任的前提和基础之上的,只要这些前提不具备,烟花爆竹的有效安全管理恐怕就只能停留在立法意图的层面上。我的初步判断是,就烟花爆竹的管理而言,这么多行政机关的存在很有可能出现“令出多门”的情况,再加上各机构往往乐于算计自己部门的“小帐”而没有动力和能力盘算整个烟花爆竹安全管理的“总帐”,机构间的相互协调和有效衔接也是一个非常困难的事,除非北京市政府有相当高超的管理能力和魄力,而且拥有充足的信息。但对北京市政府而言,这一要求其实相当高,也因此,我对这一人为复杂化的规定不太乐观。在某种程度上,我们其实应该牢记爱泼斯坦的忠告——最好以“简单规则应对复杂世界”。[71]

第三个问题在于,随着中国社会的发展和变化,该法令可能最终并不能实现其体现“民意”的主要目的。虽然我在前面已经简单论证了立法不能仅仅根据“民意”,但由于这次“禁改限”的最大动力和被人们称道的就是它能顺应变化了的“民意”,因此,我这里的分析就是要展示随着中国未来二十年快速向“老龄化”社会迈进,这一顺应了当前“民意”的法规极有可能演变为一个违背未来“主流民意”的法令。其实,就是在当前的社会里,“禁”还是“不禁”的民意也基本上是一半一半的,即使那些支持有限放开的民众其支持的前提也是政府的有效管理和燃放安全的保障。根据《北京市烟花爆竹安全管理条例》立法听证报告,虽然听证内容是讨论限放时间和限放地点,但16位代表中却有超过三成强烈反对“禁改限”,[72]除了一位医生,他们几乎全都是退休职工,是老年人。通读了《立法听证报告》后的第一感受是,与那些支持燃放的代表提供的理由(“燃放烟花爆竹是中华民族的传统民俗,不能丢”)相比,支持“禁放”,反对“禁改限”的理由(“人身伤害、火灾事故和环境问题”)更有力也更有道理,而且发现只要是老年人都坚决支持“禁放”(包括几十个旁听的老年人)。[73] 这一现象告诉我们,“禁改限”恐怕没有立法者想象的这么体现“民意”(他们的“民意”依据主要是发放的那五万多份调查问卷),而且即便是当前体现了“民意”,由于老年人坚决反对“禁改限”,更由于未来的二十年最多三十年内中国社会会快速步入一个“老龄化”的社会(很多经济学家和人口学家的研究已经表明这并不是“危言耸听”),如果也以“民意”作指标的话,我们就有理由预测这一被认为符合了当前民意的法令很有可能不符合未来中国的“主流民意”。那个时候怎么办?难道又“限改禁“吗?这其实很能说明“民意”的变化和不可靠,也暗含了以“民意”为基础的立法的薄弱。

最后也是最重要的一个问题是,禁放时解决不了的问题限放就能有效解决吗?“禁改限”

---

〔71〕 参见理查德·A·爱泼斯坦:《简约法律的力量》,刘星译,中国政法大学出版社2005年版。该书英文名直译其实就是“简单规则应对复杂世界”(“Simple Rules for a Complex World”)。

〔72〕 资料来源:“北京烟花爆竹燃放禁改限听证超三成代表反对”(新京报),http://www.aba.net.cn/news/xwzx/gnxw/20050815/084550.asp,2006年元月21日最后一次访问。

〔73〕 听证会的具体内容可以参见,“《北京市烟花爆竹安全管理条例》立法听证报告”。资料来源:http://www.beijing.gov.cn/szbjxxt/rdgz/t20050905_270683.htm,2006年元月20日最后一次访问。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

有两个主要的考虑,其一就是民众违规的的太多,既然禁不了还不如"顺水推舟"、"顺应民意"放开算了,这是一个"无奈"的选择;其二,由于原来进入北京城的"黑花炮"太多,保证不了质量,[74]希望通过"禁改限"设立专营制度和加强政府的管理工作,消灭烟花爆竹"黑市",保证烟花爆竹的安全燃放。但根据前面的相关分析,"禁改限"的这两点考虑很有实现不了的可能。虽然,由于新法刚出台时上面一般会抓得很紧,我们可以预测"禁改限"之后的头几年效果会比较好,但时间长了,这个效果肯定会大打折扣,各种潜在的问题可能就会慢慢显现出来。首先,那么严格禁止的时候都没有禁住,"限制时间、限制地点"又能限得住吗?一般来说,"限"比"禁"相对能兼顾更多的利益诉求,但执法成本往往也可能更高。由于中国老百姓尊重和遵守法律的习惯还没有养成,更由于追求"犯禁的快乐"的诱惑依然存在,因此"限不住"的可能性还是存在的。就像北京市人大一位常委担心的那样,"有可能限放以后投入的人力、物力更大,后果更严重,因为禁放很明确,我就反对你放,清清楚楚;限放以后就很麻烦了,尽管有时间、地点限制,——执法难度就更大了,——管理起来难度更大了。"[75]而且还有"前车之鉴",太原市 2000 年就已经实施了"禁改限",除指定的天数和指定的区域外,平时在市区范围内一律不准销售和燃放烟花爆竹。但自该法令实施以来,管理越来越难,"限放令"已经被人们视为儿戏,仅 2004 年上半年,就查处涉及烟花爆竹的案件 250 起,处理了 3000 多人。[76] 北京的情况会比太原好多少呢?其次,专营制度和许可证制度,还有众多管理机关真的能够消除"黑花炮",保障燃放行为的安全吗?前面的分析已经指出,烟花爆竹行业进入门槛非常低和"暴利"这两个特点其实就暗示了有关部门在生产销售环节上管理的困难,利益的驱动、市场机制的作用,再加上有"不法商人"和执法人员"勾结"的可能性,可以想象这一任务有多艰巨。这不是简单增加几个管理机关,提高市场进入门槛就能解决的。

因此,如果几个管理机关做不到工作的有效衔接,如果实践表明"限放令"的效果除了增加执法人员的"寻租"空间还不如"禁放令",如果社会的"主流民意"又发生了变化,我们可以预测大家的指责肯定会"纷至沓来",本来是为了维护法律的尊严而修改的法令将再次面临不被认同甚至被"虚无化"的境地。这其实是我们所有人都不愿意看到的结果。

六、一点余论

正如"所有的道路都通向城市"这一形象而深刻的隐喻所暗示的,在现代化和城市化"使得许多原来不构成问题的现象成为了问题"[77]之后,由于社会规范或者习惯的改变极为缓慢,政府或者立法也就在这个大背景下有了一席"用武之地"。也因此,对于很多已经不适应现代社会或者给现代社会带来了诸多不利后果的规范或习惯,比如本文着力分析的燃放烟花爆竹行为,政府或者立法的干预就获得了正当性。但不管是"禁放"还是"限放"其实都是政府安全规制的形式(只不过程度不同而已),也就在这样的考虑之下,在本文写作之初,我对究竟应该"禁"还是"限"的倾向性其实是不强的,并没有预设什么确定的结论,只是想运用法律经济学

〔74〕 "2004 年,北京市的烟花爆竹销售收入为 1200 万元,根据北京市公安局调研显示,实际销售收入在 1 亿元左右,也就是说,在北京市燃放的烟花爆竹中,只有一成多是通过合法渠道购买的,近九成是非法渠道进入北京的。"资料来源:"非法烟花爆竹销售调查:卖黑花炮一天获利两万",http://www.China.org.cn/chinese/jingji/781745.htm. 2006 年元月 20 日最后一次访问。

〔75〕 资料来源:"《北京市烟花爆竹安全管理条例(草案)》审议意见",北京市人大内务司。

〔76〕 资料来源:"春节鞭炮'禁'还是'放'——来自五城市的调查",http://www.sznews.com/tgb/20050210/ca1429863.htm,2006 年元月 20 日最后一次访问。

〔77〕 苏力:"现代化视野中的中国法治",见前注〔17〕,页 14。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的相关理论展示“禁”还是“不禁”背后的道理,而这其实也是我引用福柯的一句话作为题记所隐含的意思。

研究的最终结果却有点出乎我最初的预料,但不管怎样,我尊重和接受这一遵循了分析逻辑和客观事实的结论:“限放”很有可能还不如“禁放”。正如兰德斯和波斯纳的研究所表明的,“法律规则几乎都是包含过度(overinclusive)的,从字面理解,它们禁止了指定该规则的立法机关或法院事实上并不想禁止的某些行为。”[78]“禁放令”可能就是这个意义上的一个“包含过度”的法令,用徐昕的话来说,“这种法律事实上仍可能对人类社会产生影响,甚至是重大影响,因此反过来,它完全可能——而且是吊诡地——体现立法者的意图,也许是隐秘的意图。”[79]因此,从这个角度,我们完全有道理认为,废止“禁放令“而代之以增加了管理难度而且有可能实施效果不会太好的“限放令”就不是一个明智的选择。

这是一个基于当代中国变迁事实和法律经济学基本逻辑得出的结论。但以尼采和福柯所倡导的谱系学眼光来看,由于其要求我们尽量洞悉事件背后的种种细节和偶然,"限放令"这一可能有大量潜在后续成本的法律得以顺利出台的原因可能更为琐细和复杂。比如,公安机关在长达十几年的执法实践中集聚的怨气和不满(不仅在别人都合家团聚的新年期间还要例行公事似的出勤,而且补助低,出勤的效果还不好);前面提到过的供销社系统强大的部门利益,以及这一利益背后体现的政府对国有企业的支持,对供销社系统职工这一在市场经济大潮中日渐衰落的“弱势群体”的保护;最近几年来中华传统文化的复兴以及相关宣传;流行“民意”的变化,特别是那些声音(voice)最为响亮的民意;甚至还不排除这一届政府和人大想要在政绩上有所作为的动机(而修改上一届政府提议,上一届人大通过的“禁放令”可能就意味着某种程度上的政绩,从而能获取一定的政治资本)。

由于我的视野和搜集的资料所限,实际上的制约因素可能比上面提到的更多。但透过这些左右和挤压“禁放令”出台的种种力量,我们也可以看到,单单一种力量,即使是强大的民意(虽然在“禁改限”中,支持开禁的民意并不那么强大),恐怕也不是主宰这一事件的唯一动力。而上述几种力量纠缠、合谋、争斗后形成的那股合力可能才是“禁改限”得以快速出台的真正原因。

仅从以上的分析看来,我们承认这一合力的现实性和必要性,这一看问题的角度甚至还有可能使我们对“禁改限”有了一种同情的理解。但这并不是我们认同并接受“禁改限”的理由,由于该合力缺少了理性的经济学思维以及后果主义的考量这两股重要和有力的参与力量,从而很有可能偏离应有的调控社会生活的目标。这其实也是我花费诸多笔墨强调立法过程中经济学思维的重要性和必要性之所在。

〔78〕 威廉姆·兰德斯,理查德·波斯纳:“私人执法”,《制度经济学》第3期,顾红华、徐昕译,经济科学出版社2004年版,页246-280。

〔79〕 徐昕:《论私力救济》,中国政法大学出版社2005年版,页249。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net